



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 104/11

התובעים:

1. בנימין ביטון
2. יורשי המנוחה מרסל ביטון ז"ל ואח'
ע"י ב"כ עו"ד מ. היילבורן
רח' בן יהודה 1, ירושלים

- נ ג ד -

התובעים:

יוסף ויעל עוזיאל
ע"י ב"כ עו"ד י. ריסקין
רח' יד חרוצים 15, ירושלים

פ ס ק – ד י נ

עניינה של התביעה בדרישת התובעים ליתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים, האוסר עליהם או על מי מטעמם לבצע כל פעולת בניה בבית המשותף בגוש 30141 חלקה 9 בירושלים (להלן: "הבית או הבית המשותף"), וכן ליתן צו המורה להם לפרק את הפרגולה בגודל של כ- 9-10 מ"ר שבנו הנתבעים עובר לרכישת דירתם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית המשותף בגוש 30141 חלקה 9 בירושלים ברחוב מקור חיים 22 בירושלים.
2. על פי המצב הרשום כיום בפנקס הבתים המשותפים, בבית המשותף ישנן שלוש תתי חלקות. התובעים הינם בעלי ה זכויות בדירות 1 ו-2 [חלקם רשומים כבעלי הדירות וחלקם זכאים להירשם מכח צו ירושה שניתן ביום 7.7.08]. הנתבעים הינם בעלי הזכויות בדירה מס' 3 בבית המשותף.
3. בצו רישום הבית המשותף נקבע, כי לדירה מס' 1, המצויה בקומת המרתף "צמוד לגג [כך במקור – ש.ה.] שמעל הדירות מס' – 2,3"; לדירה מס' 2, המצויה בקומת הקרקע "צמוד לה חצר כולל סככה ו מחסן המסומן באות "א" ובצבע כחול; ולדירה מס' 3, המצויה אף היא בקומת הקרקע, "צמוד לה חצר המסומנת באות "ב" ובצבע אדום".
4. ביום 9.10.62 נחתם צו תיקון לבית המשותף, אשר קבע כי: "הצמידות ליחידת המשפח [כך במקור – ש.ה.] מס' – 9/2 תבוטל...". כן נקבע, כי ליחידת משנה 9/2 "צמוד לה החצר הכולל סככה ומחסן המסומן באות "א" ובצבע כחול וכן שטח הקרקע שבפינה הצפונית מזרחית המסומנת באות "ג" ובצבע כחול כהה ובשטח של 3X3 מ"מ". בנוסף נקבע, כי "שטח החצר המסומן בתס ריט באות "ב" ובצבע אדום יקטן ע "י נכוי שטח של 9 מ"מ שהנו שטח הפינה המסומן באות "ג" ובצבע כחול כהה".
5. על פי נסח הרישום, שטחה של דירה 1 הינו 68 מ"ר, של דירה 2 הינו 96 מ"ר, ושל דירה 3 הינו 45 מ"ר. בהתאם לשטחים הללו נקבע גם חלקם היחסי של בעלי הדירות ברכוש המשותף, ומכאן שחלקם של התובעים ברכוש המשותף הינו כ- 78 אחוזים.
6. הנתבעים הגישו בקשה להיתר בניה להרחבת דירתם, בשטח הצמוד לדירתם. על פי מסמכי הבקשה מדובר בתוספת של כ- 100 מ"ר שטח עיקרי ועוד כ - 12 מ"ר שטחי שירות, כאשר התוספות מתייחסות לקומת הקרקע, הקומה הראשונה וקומת הגג [להלן: "תכנית הבניה"]. בהקשר לכך יוער כי התובעים טענו כי התכנית גלשה גם לשטח המצוי בגג דירת ס, אך ה נתבעים הבהירו כי אין הם מתכוונים לבנות בשטח שאינו צמוד לדירתם.
7. בנוסף, בנו הנתבעים פרגולה בשטח של כ - 9-10 מ"ר, הכוללת קירות מכל הכיוונים, הבנויים חלקם מזכוכית וחלקם מחומרים אחרים [ר' עמוד 6 שורה 9 לפרוטוקול הדיון מיום 25.5.12, כן ר' תמונות נספח ד' לכתב התביעה ומוצג ת/6 – להלן: "הפרגולה"]. אין חולק כי בניה זו בוצעה על שטח הצמוד לדירת ה נתבעים [ר' עמוד 2 שורות 17-32 לפרוטוקול מיום 25.5.11, וכן סעיף 5 לכתב התביעה].



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

8. ביום 11.10.10 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים את תכנית הבניה. על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הגישו התובעים ערר, וביום 10.4.11 קבעה ועדת הערר כי יש לדחות את הטענות התכנוניות של התובעים, אך יש מקום לבירור טענותיהם הקנייניות.
9. בעקבות זאת, הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים, וכן בקשה לצו מניעה זמני. ביום 15.5.11 ניתן צו מניעה ארעי, ולאחר דיון בבקשה ניתן צו מניעה זמני ביום 1.8.11.

ב. טענות הצדדים:

01. התובעים טוענים, כי הנתבעים מנועים מלבצע בניה כלשהי, אף בשטח הצמוד לדירתם, ואף אם הם מנצלים את אחוזי הבניה הנגזרים מחלקם ברכוש המשותף. לטענתם, הואיל וזכויות הבניה שייכות במשותף לכלל הדיירים בבית המשותף, ובהיעדר הוראה מפורשת בתקנון אודות הזכות לבנות בשטח ההצמדה, אין לאפשר מימוש אחוזי בניה, ללא שהוכח הרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק.
11. לטענת התובעים, מאחר שהם בעלי הזכויות הרשומים ב- 2/3 מהדירות, אשר 78% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לא תתאפשר בניה ללא הסכמתם, וזאת בהתאם לרוב הדרוש בסעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 [להלן: "החוק"].
21. לטענת התובעים, לאחר שמיעת הראיות הוכח באופן חד משמעי, כי הנתבעים לא קבלו את ההסכמות הנדרשות בסעיף 71 לחוק. בתוך כך, מפנים התובעים לעדות הנתבע בעמוד 12 שורה 12 לפרוטוקול שהעיד כי "הגשתי את זה בסופו של דבר ללא הסכמה כי ראיתי שאין עם מי לדבר". כן מפנים התובעים לעדות הגב' צביה פישר בעמוד 6 לפרוטוקול, ולתצהירו של העד מטעם הנתבעים, מר פרג'י, התומכים בטענתם כי מעולם לא ניתנה הסכמה לבניה. בנוסף מפנים התובעים להסכם המכר בין הנתבעים למי שמכר להם את דירתם [מוצג נ/3] ממנו עולה, לטענתם, כי לא נתנה להם הבטחה כלשהי בעניין הסכמה לבנייה המבוקשת על ידם.
31. עוד טוענים התובעים, כי בניית יחידה חדשה מצריכה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, דבר שלא התקבל במקרה דנן.
41. מוסיפים התובעים וטוענים, כי מכל מקום הגג החדש שייוצר כתוצאה מהבניה על ההצמדה הופך לאלתר לרכוש משותף, וממילא דרושה הסכמתם לבניית הקומות העליונות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

51. מוסיפים התובעים וטוענים כי ניצול זכויות בניה , וגם ניצול יחסי , מקטין את ערך יתר הדירות, ולכן לא ניתן לבצע זאת ללא ההסכמה הנדרשת בחוק . במקרה דנן, כך לטענתם, ניצול זכויות הבניה אף יסכל תכנון עתידי ראוי בבית המשותף, דבר שבהכרח ישפיע לרעה על ערך דירותיהם.
61. התובעים טוענים, כי התנגדותם לבניה הינה בתום לב מוחלט , והיא נובעת מהפגיעה הקשה שתיגרם להם כתוצאה מהבניה. לטענתם הבניה תחשיך את דירותיהם, ואף תסכל, כאמור, כל אופציה לבניה עתידית בחלקה . כמו כן, לטענתם, הבניה תגרום לשינוי חזית הבית המשותף, ולמצב בו לא ניתן יהיה למצוא פתרון חניה הולם . אף בעניין זה מפנים התובעים לעדותה של הגב' פישר בעמוד 16 לפרוטוקול.
71. לטענת התובעים, אמנם הם פיצלו את דירותיהם למספר דירות , אך מדובר בשינויים פנימיים, שבוצעו ב שנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת , וזאת, בידיעתם ובהסכמתם של קודמי הנתבעים.
81. התובעים טוענים, כי הנתבעים פועלים בחוסר תום לב בב יצוע בנייה ללא הסכמה וללא היתר כדין. בעניין זה מפנים התובעים גם לכך שהנתבעים בנו את הפרגולה בשטח של כ- 10 מ"ר, ללא היתר בניה , ומפנים להודאת הנתבע בעמוד 6 שורה 9 ובעמוד 7 שורה 11 לפרוטוקול הדיון מיום 25.5.11.
91. בכל הנוגע לטענות הנתבעים ביחס לשיהוי , ולהיעדר יריבות, מפנים התובעים להחלטתי בסעד הזמני מיום 1.8.12.
02. התובעים טוענים כי אין להיעתר לבקשה שעלתה בסיכומי הנתבעים להורות על פירוק שיתוף באחוזי הבניה , הן משום שדרישה זו נוגדת מהותית את ההוראות הנוגעות לבית המשותף, והן מאחר שהדבר אינו בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.
12. אשר לטענת הנתבעים , כי התובעים בצעו הרחבה דומה בכך שאבי התובעים בנה דירה נוספת, טוענים התובעים כי לא מיניה ולא מקצתה . לטענתם, כל שבוצע הינו בניה על פי ההיתר, ומכל מקום בניה זו קדמה לרישום הבית המשותף , בעוד המבחן ל "הרחבה דומה" בוחן את הדברים בהתאם למצב לאחר רישום הזכויות . בכל הנוגע לטענות הנתבעים בעניין בניית מרפסת על ידי התובעים, טוענים התובעים כי אכן בוצעה הגבהת מילוי לצורך מרפסת חיצונית, אך מעבר לכך לא בוצעה בניה כלשהי מעבר לקונטור הבית כמתואר בתשריט הבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

22. התובעים טוענים כי דווקא התנהלות הנתבעי ם אשר כופים עליהם את הבניה , היא התנהלות חסרת תום לב , תוך שהם מנסים בהתנהלותם השתלטנית להכתיב להם כיצד לנהוג בבית המשותף למרות שהתובעים הם הרוב המוחלט של בעלי הזכויות בו.
32. לאור כל האמור, טוענים התובעים, כי יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע בניה כלשהי לרבות בשטח הצמוד לדירתם ; להורות על הריסת הפרגולה, ולפסוק כנגדם הוצאות המשקפות את חומרת התנהלותם . למען הסדר הטוב יצוין , כי בסיכומיהם, זנחו התובעים חלק קטן מהדרישות שביקשו בסעיף 15 לכתב התביעה.
42. מן העבר השני טוענים הנתבעים, כי יש לדחות התביעה מכל וכל. לטענתם, התביעה נגועה בחוסר תום לב קיצוני, ומנוסחת באופן המטעה את המפקח על רישום המקרקעין . לטענת הנתבעים, הבניה אינה פוגעת כלל בתובעים , שכן הוכח שהיא אמורה להתבצע אך ורק על השטח הצמוד לדירת הנתבעים ותוך ניצול חלקם היחסי באחוזי הבניה.
52. לטענת הנתבעים, יש לדחות תביעה גם משום שהוגשה בשיהוי ניכר המגיע עד כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. עוד טוענים הנתבעים כי הבקשה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים שכן אף התובעים ביצעו תוספות בניה בכך שבנו מרפס ות בצדו של הבית המשותף, פיצלו יחידות, ופרצו חללים בקירות הבית המשותף.
62. התובעים טוענים עוד, כי דירתם קטנה ביותר (45 מ"ר) והם רכשו אותה על סמך ההנחה שניתן יהיה להרחיבה בשטח הצמוד לה ועל חשבון אחוזי הבניה היחסיים . לטענת הנתבעים הם אף שוחחו עם מר ביטון על תוכניותיהם בטרם רכשו את הדירה , אך הלה דחה אותם ב "לך ושוב", עד שהחליטו להגיש תכניותיהם למוסדות התכנון ללא הסכמת התובעים.
72. לשיטת הנתבעים אין תחולה לסעיף 71 לחוק בענייננו , הן משום שזכויות בניה א ינן "רכוש משותף " והן משום שסעיף 71 מתייחס לבניה על שטח שהינו רכוש משותף . לטענת הנתבעים , אין כל מניעה שבעל דירה יבנה על שטח הצמוד לדירתו בניה שאינה חורגת מהיקף זכויות הבניה היחסיות המוקנות לו.
82. מוסיפים הנתבעים , כי התובעים או קודמיהם ביצעו הרחבה בעבר ובנו דירה חדשה בצמוד לדירת הנתבעים . לפיכך, יש לראות אותם כמסכימים להרחבה דומה של דירת הנתבעים. בעניין זה מפנים הנתבעים למסמכים שצורפו מתיק עיריית ירושלים המ עידים, לטענתם, על ביצוע ההרחבה כאמור. כן טוענים הנתבעים כי הוכח שהתובעים בנו מרפסת בשטח של 15 מ"ר, בנו מחסן נוסף בשטח של כ 7 מ"ר, סגרו מרפסת בצד המערבי של הבית, ביצעו גם הרחבה לכיוון דרום, ואף עושים שימוש למגורים במחסן המצוי בחצר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

92. לטענת הנתבעים כל פסקי הדין המצוטטים בסיכומי התובעים אינם רלוונטיים מאחר שהם עוסקים בבניה על רכוש משותף, וכן קובעים כי בעל דירה לא זכאי לכל זכויות הבניה על השטח הצמוד לדירתו.
03. לטענת הנתבעים עמדת התובעים נוגדת את הפרקטיקה המקובלת ואת מושכלות היסוד. לשיטתם, מאחר שזכויות בניה אינן רכוש משותף, חלים עליהן דיני השיתוף הכלליים, הקובעים כי כל שותף רשאי לעשות בחלקו שימוש סביר כל עוד אינו פוגע באחר. לטענתם, ניצול אחוזי בניה יחסיים אינו יכול לפגוע באחר ולכן יש להתירו ללא הסכמת יתר בעלי הדירות. לחילופין טוענים הנתבעים, יש להתיר להם פירוק שיתוף בזכויות הבניה.
13. הנתבעים טוענים כי התנהלות התובעים הינה חסרת תוס לב, שכן התנהגותם מונעת מהם כל אפשרות לנצל את אחוזי הבניה השייכים להם, ומחייבת אותם לחיות בצפיפות לחינם. הנתבעים מפנים לעדויות שנשמעו התומכות בכך שהם ניסו כל דרך אפשרית כדי להגיע לעמק השווה עם התובעים, אך הללו אינם מוכנים לכל פתרון מלבד רכישת דירתם תמורת "נזיד עדשים". בהקשר לדברים הללו טוענים הנתבעים כי דוקטרינת תוס הלב חלה גם על זכויות במקרקעין.
23. לטענת הנתבעים, הוכח כי לא ייגרם לתובעים כל נזק מהבניה המבוקשת על ידם, דבר המוכיח כי אין מדובר אלא ב התעמרות התובעים בנתבעים, על מנת להשיג את מבוקשם. בתוך כך מפנים הנתבעים לעדויות התובעים [עמוד 6 לפרוטוקול] מהן עולה כי אין להם כל כוונה לבנות. כן מפנים הנתבעים לכך שהתובעים מסרבים לכל הידברות ולכל פגישה עם אדריכל על מנת להניח דעתם, ומחזיקים את הנתבעים כבני ערובה. הנתבעים מוסיפים כי לא הוצגה כל ראיה לטענה שיש בבניה כדי לפגוע בתובעים.
33. לטענת הנתבעים, הוכח כי כל שעשו הינו הצבת פרגולה בחצר הצמודה לדירתם במקום מרפסת מקורה בגג אסבסט שהיתה קיימת זה עשרות שנים. לטענת הנתבעים נושא זה אף אינו בסמכות המפקח על רישום המקרקעין קעין שכן מדובר בחצר הצמודה לדירת הנתבעים. בהקשר לכך מפנים הנתבעים לתצהירים, ומנגד לעדותה של הגב' פישר [עמוד 7 לפרוטוקול] שהודתה כי היא אינה זוכרת את שהיה במקום לפני הפרגולה.
43. לטענת הנתבעים הם לא הציבו מתקנים על גג הבית המשותף, והתובעים אף זנחו נושא זה בסיכומיהם.
53. הנתבעים טוענים, כי מכל מקום הסעד הנדרש, קרי, מתן צו האוסר כל בניה, הינו גורף וקיצוני, שכן בכל מקרה ניתן להקים במקום ממ"ד שאינו מנצל זכויות בניה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

63. הנתבעים מסכמים כי התובעים נוהגים כמידת סדום , וכי הדין והצדק מורים כי "כופין על מידת סדום".

ג. דיון:

73. שורש מחלוקתם של הצדדים בשאלה , האם מקום בו בעל דירה תובע לנצל את חלקו היחסי בזכויות הבניה ולבנות על שטח הצמוד לדירתו , נדרשת הסכמת הרוב בהתאם לסעיף 71 לחוק, או שמא במקרה כזה רשאי בעל הדירה לנצל את חלקו היחסי ללא קבלת רשות ממאן שהוא . רוב הדיון המשפטי מוצה כבר עת דנתי בבקשה ל צו המניעה הזמני, ואחזור על עיקרי הדברים למען הסדר הטוב , ועל מנת לחדד מספר נקודות הדרושות חידוד.

83. **מהותן של זכויות הבניה** : זכויות בניה אינן חלק מהרכוש המשותף כהגדרתו בחוק , אלא מהוות נכס כלכלי רב ערך המצוי בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. כך סיכם זאת בית המשפט העליון בע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור**, תק-על 2009(3), 3111 :

"...הפסיקה קבעה, כי אחוזי בנייה הם נכס משותף , אך הם אינם רכוש משותף '...חרף העובדה לפיה "אחוזי בנייה " או "זכויות בנייה" אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף נקבע כי מדובר בנכס בעל ערך כלכלי (ראו עניין ביבי לעיל , בעמ' 501 ; עניין גלמן לעיל , בעמ' 393) הנמצא בבעלות משותפת של הדיירים בבית המשותף וכפי שציין הנשיא שמגר : "זכויות הבניה הינן נכס בבעלות משותפת , אף-על-פי שאינו חלק מן הרכוש המשותף . הזכויות הללו נובעות מהבעלות בקרקע , וכיוון שהקרקע עליה ניצב בית משותף שייכת במשותף לדיירים, אף זכויות הבניה עליה שייכות להם במשותף..."
(עניין מזרחי לעיל , בעמ' 680 ; וראו גם עניין גלמן לעיל , בעמ' 393).
...מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של בעלי הדירות בבית המשותף..." (הדגשה לא במקור).

93. בהינתן העובדה שזכויות הבניה הינן בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות , נקבעה ההלכה שלפיה לא יתאפשר רשאי בעל דירה לבצע פעולות בניה על השטח שהוצמד לו, אלא אם הותר הדבר, מפורשות, בתקנון הבית המשותף [ר' למשל : ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי**, פ"ד נד(3), 389].

04. זאת ועוד : היות שזכויות הבניה הינן נכס בבעלות משותפת , הבעלות של בעלי הדירות מתפשטת בכולן , ואין שותף רשאי לנצל אף את חלקו היחסי בשטח מסוים. כך הבהיר זאת פרופ' דויטש [מ. דויטש, **קניין**, כרך א', 694-693]:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"הנקודה עתה היא, שאף אם הבנייה נעשית בחלק פתוח שהוצמד לדירה נתונה, הרי שאחוזי בנייה הם נכס אחר כשלעצמו – נכס מופשט משותף – ואין שותף יכול ליטול לעצמו זכויות ייחודיות בנכס המשותף, ללא הסכמת האחרים. כך, במספר מקרים נפסק, כי הצמדה של הגג בתקנון, לבעל דירה נתונה, אינה כורכת עימה באופן אינהרנטי גם העברה אליו של אחוזי הבניה המתאימים" (ההדגשה לא במקור).

14. באופן דומה נקבע גם בפסק הדין ב רע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ, תק-על 2010(3), 2320 (להלן: "פס"ד פל"):

"ברגיל, הצמדה של שטח לדירה מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד אך אינה מקנה לו זכות לבנות על השטח המוצמד, וניצול זכויות הבנייה בבית המשותף מותנה אפוא בהסכמת יתר בעלי הדירות...ובקיצור, גריעה של חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת אין פירושה שיוך של אחוזי הבניה לאותה דירה (ההדגשות לא במקור).

24. נמצאנו למדים, כי זכויות הבניה שייכות לכל בעלי הדירות במשותף, ולפיכך, באופן עקרוני, לצורך פעולה של ייחוד זכויות הבניה לדירה מסוימת, דרושה הסכמת כל בעלי הדירות, וזאת גם מקום בו הבניה אמורה להתבצע על שטח הצמוד לדירה מסוימת.

34. יחד עם זאת, במסגרת תיקון מס' 18 לחוק, משנת 1995, ביקש המחוקק להקל על בעלי דירות בבית משותף להרחיב דירתם תוך ניצול אחוזי הבניה הקיימים בדין, ולמנוע מצב בו מיעוט מצומצם יחסום אותם מלעשות כן. [ר': א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 211; כן ר': דברי הכנסת, כרך 133, עמוד 1797]. בתוך כך, חוקק סעיף 71 לחוק, אשר קבע כי ניתן להסתפק ברוב מיוח ד הן לשם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, והן על מנת לבצ' ע חלוקה של זכויות הבניה. סעיף 71 קובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות..." (ההדגשה לא במקור).

44. סעיף 71 לחוק קובע אפוא, בין היתר, כי לצורך הרחבת דירה ניתן להחליט על חלוקת זכויות הבניה ברוב מיוחד של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. לאמור, אין עוד צורך בהסכמת כל בעלי הדירות לשם חלוקת זכויות הבניה, וניתן להסתפק ברוב שנקבע בסעיף.

54. עיינו הרואות, כי עצם חלוקת זכויות הבניה מחייבת הסכמת רוב, הזהה לזה הנדרש לצורך הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף. ודוק: הסעיף אינו מאבחן בין מקרה בו בעל דירה תובע לנצל את חלקו היחסי בלבד לבין מקרה בו הוא תובע לנצל זכויות בניה של אחרים - כך או כך, פעולת ייחודן של זכויות הבניה לדירה מסויה ימת דורשת את הסכמת הרוב המיוחד כאמור.

64. באופן דומה פירש פרופ' דויטש את סעיף 71ב [מ. דויטש, שם, 696]:

"מטרות מעשיות, הנוגעות למצוקת דיור, וגישה רעיונית השוללת הקניה של זכות וטו מוחלטת לכל בעל דירה לעניין בניה ברכוש המשותף...הובילו לחקיקתו לאחרונה של תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אשר אנו תובעים עתה לעיין בהיקפו ופריסתו. לבעלי רוב מיוחד בבית המשותף הוקנה הכח להחליט על הפקעה של חלקים ברכוש המשותף, תוך הצמדתו לדירה נתונה, ועל ביצוע חלוקה - למעשה מעין פירוק של השיתוף - של זכויות הבניה הבלתי מנוצלות, וזאת על מנת לאפשר את הרחבתה של הדירה אליה מצמידים את אותו חלק. לעניין אחוזי הבניה, אין מדובר, אמנם, בהפקעה של אחוזי הבניה, כאמור, אלא בחלוקתם. אולם חלוקה זו אינה נעשית בדרך של הכרעה שיפוטית בדבר פירוק השיתוף, אלא בדרך של החלטת רוב, ובמובן זה קיימת פגיעה בבעלי המיעוט, לעומת הדין הכללי ביחס לפירוק שיתוף" (ההדגשות לא במקור).

74. ראייה נוספת לכך שסעיף 71ב לחוק חל כל אימת שמתבקש ניצול זכויות בניה בבית המשותף, אף מקום בו בעל דירה תובע לנצל את זכויות הבניה היחסיות, ניתן להביא גם מפסק הדין בעניין פל הנ"ל. בפסק הדין, הגם שהדברים נאמרו "למעלה מן הצורך", ושלא על מנת "לקבוע מסמרות" (ר' פסקה 16 לפסק הדין), הביע בית המשפט העליון דעתו כי גם מקום בו בעל דירה תובע לבנות על שטח הצמוד לו הוא נזקק לרוב הקבוע בסעיף 71ב לחוק. בית המשפט פסק כדלהלן:

"מכאן השאלה אם יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות לשם ניצול אחוזי הבניה...קשה להלום כי מצבו של מי שתובע לבנות על החלק הצמוד לדירתו מימים ימימה, יהיה גרוע ממצבו של מי שתובע לבנות על רכוש משותף שהוצא והוצמד לצורך בניה כאמור. שהאחרון יסתפק ברוב של שלושה רבעים מהדירות ששני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, ואילו הראשון יידרש לקבל הסכמתם של כל בעלי הדירות...לכן דומני כי יש להעדיף פרשנות לפיה הסעיף יחול גם כאשר מדובר ברכוש משותף שכבר הוצמד לדירות השונות ונדרשת הסכמה לניצול אחוזי הבניה על החלק הצמוד, ואין לצמצם תחולת הסעיף רק למקרה של החלטה הכוללת הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתה לדירה פלונית לבניה שמטרתה הרחבת אותה דירה..."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

84. לא למותר להדגיש, כי גישה זו אף תביא להגשמת תכלית המחוקק אשר ביקש לשמור על ייחודו של הבית המשותף, ולאזן בין זכויות הקניין של בעלי הזכויות בו. מטבע הדברים, פעולת בניה, אף אם היא מבוצעת בשטח הצמוד לדירה מסוימת, ואף אם היא מנצלת רק את אחוזי הבנייה היחסיים של בעל הדירה המבקש לבנות, משנה באופן מהותי את הבית המשותף, וצודקים התובעים, כי ככלל, מצב בו כל בעל דירה ירחיב את דירתו כראות עינו עלול להביא לאנדרלמוסיה בבית המשותף. לכן, ראוי הוא כי ייקבע שבעל דירה אינו רשאי לעשות בחלקו היחסי בזכויות הבניה כרצונו, ללא נטילת הסכמת הרוב הדרוש לכך.
94. סיכומו של דבר – אף במקרה ש בעל דירה מעוניין לנצל את חלקו היחסי בזכויות הבניה בשטח השייך לו, חלות הוראותיו של ס ע"פ 71 לחוק, ולשם ביצוע ההרחבה עליו לקבל הסכמה של מי שבבעלותם 75% מהדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
05. בטרם אפנה לגופו של עניין, מוצא אני מקום להעיר כי האמור לעיל הינו על דרך הכלל. עם זאת, יש להותיר ב"צריך עיון" את השאלה האם הדברים האמורים חלים גם במקרה בו אחוזי הבניה היחסיים מוענקים בתכנית סטוטורית לכל דירה ודירה בנפרד, ובאופן שאינו מקפח כלל דירות אחרות. במקרים אלו יהיה עלינו לדון, בין היתר, בשאלה האם עדיין יש לראות בכך נכס המשותף לכל בעלי הדירות אם לאו. שאלה זו אינה עולה במקרה דנן ואינני מכריע בה כעת.
15. כמו כן חשוב לציין עוד, כי לא מן הנמנע שיש מקום לטענה כי ניתן לפנות בבקשה מתאימה לפירוק שיתוף של זכויות הבניה, באופן שכל אחד מהשותפים יהא זכאי לנצל את חלקו היחסי בזכויות הבניה [כפי שנעשה במקרה מושא פסק הדין בת"א (מחוזי יר') 3014/01 **אלי אזולאי נ' אברהם אילוז**, תק-מח 2002(2), 69182], כאשר בתוך כך תישאל השאלה האם דיני פירוק השיתוף חלים על זכויות בניה [שאינן רכוש משותף כאמור] בבית משותף. מכל מקום, שאלה זו אינה בסמכותו העניינית של המפקח, וממילא כל עוד לא פורק השיתוף, הדרך היחידה ליחד את זכויות הבניה הינה בהתאם לכללים הק בועים בסעיף 71 לחוק, כמוסבר.

ד. מן הכלל אל הפרט:

25. אין חולק כי ה תובעים הינם בעלי הזכויות ב- 2/3 מהדירות שבבית המשותף כש- 78% מהחלקים ברכוש המשותף צמוד לדירותיהם. מחומר הראיות עולה כי התובעים לא הסכימו לבניה שמבקשים הנתבעים לבצע [ר': עמוד 12 שורה 12 לפרוטוקול שם העיד עד הנתבעים כי "הגשתי את זה בסופו של דבר ללא הסכמה כי ראיתי שאין עם מי לדבר"].



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

35. משאלו הם פני הדברים, ולאור המוסבר לע יל, כי תנאי לייחוד ומימוש זכויות בניה במקרים כגון המקרה דנן, הינו קבלת הרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק, אין אלא לקבוע כי הנתבעים מנועים מלבצע את הבניה המבוקשת על ידם בתכנית, מאחר שהם לא עברו את הרף הנדרש בסעיף 71 לחוק.

45. הנתבעים טענו כי יש לאשר את מבוקשם לאור העובדה כי התובעים אינם תמי לב. אינני מקבל את הטענה. לא מצאתי בהתנהלותם של התובעים חוסר תום לב כפי שנטען על ידי הנתבעים. העדה מטעם התובעים נימקה את התנגדותה בכך שהבניה תפגע בחזית הבית ותשנה את אופיו, תחשיך את דירות התובעים, ואף עלולה לפגוע לשיטתם בבניה מיטבית עתידית. כך העידה העדה בעניין זה [ר' פרוטוקול הדיון מיום 6.10.11 עמוד 6 שורות 25-31]:

ת. אני מתנגדת לכל בניה. אנחנו יושבים על מגרש אחד. אנחנו במגרש 78%. הוא לא ביקש הסכמתנו. אנחנו לא רוצים לבנות. לא רוצים לשנות חזית. לא רוצה למנוע את האפשרות של חניה מתחת ל בניין. לא רוצה למנוע בניה עתידית. אני לא רוצה להיגרר להרפתקה שלא אוכל לחזור ממנה אח "כ ואני אתקע. הוא מחשיך לי את הבית, נכנס לי לפרטיות.

ת. אנחנו לא מסכימים גם אם יהיו שינויים כאלה או אחרים. זהו בניין ישן. צריך לעשות משהו יסודי. אי אפשר להיתקע עם משהו שיהיה לרעת כולם.

55. ואכן, מביקור שערכתי במקום [שלא במעמד הצדדים], נוכחתי כי חלק מנימוקים אלו אינם משוללי הגיון. כך למשל, אין ספק כי מדובר בבית ישן ומיוחד, אשר הבניה המוצעת תשנה את אופיו מהקצה אל הקצה. אין גם ספק שללא תכנון משולב ומתואם, עלולה להיפגע האפשרות לניצול מלא של זכויות הבניה בקרקע. בנסיבות אלו, אין לראות בסירוב התובעים ככזה המצדיק התערבות הערכאה השיפוטית.

65. בעניין זה לא למותר לצטט מפסיקתו של בית המשפט המחוזי ב עש"א 13877/09 אילן קיסרי נ' שאחב שלומוב (חיפה) [פורסם בפדאור], אשר הבהיר מה מידת התערבותה של הערכאה השיפוטית בבחינת תום הלב:

"...זאת ועוד, נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש משותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובנייה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער, הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. על המבקש לבנות ברכוש המשותף לפעול, בטרם התחלת הבנייה, לקבלת ההסכמה של כל הדיירים. לעיתים עליו לכנס אסיפת דיירים ולעיתים די שיפנה לשאר הדיירים בבית המשותף לקבלת הסכמתם. דייר המתחיל לבנות ללא פניה לשאר בעלי הבית פועל בחוסר תום לב. גם אם לא מושגת ההסכמה, משיקולים הנראים בעיני המבקש כפסולים, אל לו לעשות דין לעצמו ועליו לנקוט בהליך מתאים בבית המשפט או בפני המפקחת כדי לכפות את ההסכמה...זאת ועוד, לגישת חברי על המתנגד לבנייה לשכנע כי עומדים לו



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

נימוקים ענייניים וסבירים על פי מבחן אובייקטיבי . איני יודע מהם אותם נימוקים שיעמדו במבחן האובייקטיבי , ודומני כי התנגדות של אדם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף תהא בדרך כלל התנגדות עניינית . אין כל מקום לכפות על אדם לוותר על קניינו רק בשל רצון של שכן לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. גם עמידתו של דייר על קבלת טובת הנאה כלשהי כתנאי למתן הסכמתו לוותר על זכויותיו , אפילו טובת הנאה כספית , אינה מהווה בהכרח חוסר תום לב . גם התנגדות בשל החשש לירידת ערך הדירה של המתנגד אינה חסרת תום לב.

אוסף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקום ומס של בעלי הדין . עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף , אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים.

75. על דברים אלו חזר גם בית המשפט המחוזי בחיפה ב עש"א 17181-05-11 אברהם נ' פדאל ואח' [פורסם בפדאור] :

"במקרה דנן, גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי המתנגדים , סבור ההרכב שטענה כבוד המפקחת משסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש לראות את אלה , כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת לבוא לשקול את השיקולים על ידה , במקום הדיירים האחרים. סמכות כזו אינה קיימת....לעניין הטענה כי ייווצר מעין זכות וטו לדיירים בבניין הקדמי בנוגע לכל בנייה שיתבקשו הדיירים לבצע בבניין האחורי , יש להשיב , כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה , ובכל מקרה, בדעת רוב (השופטים ש' וסרקרוג והשופט ר' שפירא) אם אכן תהיה ההתנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט , הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת...

...השופטת ש' וסרקרוג, ס' נשיאה: בנסיבות העניין ומאחר שהייתה הסתמכות, בין היתר , על דברים שנאמרו על ידי בפס "ד צבי , אין לי אלא להצטרף שהיישום היה כפי שהיה בפסק דין זה . לדעתי, לא ניתן היה בהתבסס על פס"ד צבי כדי להרחיב את סמכות הבדיקה שניתנה למפקחת גם על פי דעתי , להגיע לתוצאה אליה הגיעה בתיק זה. גם הגישה הסוברת – על פי דעתי – כי יש למפקחת סמכות לברר את נימוקי ההתנגדות, אין בית המשפט צריך לשים עצמו במקומם של בעלי הדין, ולעניין זה מפנה אני לדברים שנאמרו ע"י כבוד השופט סוקול בעש"א 13877-04-09. ראשית, יש להזכיר כי בפס "ד צבי , על אף שעקרונית הצטרפתי לדעתו של כבוד השופט זרנקין לפיה יש סמכות למפקח לבחון נימוקי התנגדות , הרי משיושם העקרון האמור , ונבחן על פי הנימוקים שפורטו באותו מקרה , הצטרפתי לתוצאה עליה הצביע כבוד השופט יצחק כהן . שנית, ראוי להבחין היטב בין עצם השאלה אם בעל דין המתנגד לבקשת שכנו לבנות ברכוש המשותף יכול לבוא לבית המשפט ולומר "מתנגד אני", ללא הוספת כל נימוק , ודי בכך כדי למנוע הבנייה , ולמעשה לצמצם או למנוע את סמכותו של בית המשפט או של המפקחת לדרוש פירוט נימוקי ההתנגדות , לבין היקף יישום סמכותו של בית המשפט לבקר את הנימוקים שהועלו . בשאלה הראשונה שהיא העקרונית , אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה " עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות , אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב – שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה . בשלב השני



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר. אכן, אין לאפשר לדעתי התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש ברעה לזכות הקניין, כך נאמרו על ידו בפס"ד צבי והוספתי שם כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה..."
[ההדגשות לא במקור]

85. דברים אלו יפים גם למקרה דנן - ייתכן מאוד כי התועלת הכללית שתצמח מבניה הינה רבה עד מאוד [לכל הצדדים המעורבים], ואולם נימוקי התובעים אינם משוללי יסוד ולכן אין לראות בסירוב התובעים לבניה בבית המשותף דנן, כסירוב חסר תום לב.
95. אף את טענת הנתבעים שלפיה יש להתיר להם את הבניה על פי תכנית הבניה, נוכח "הרחבה דומה" שביצעו התובעים בעבר, אין בידי לקבל. בטענה זו מסתמכים הנתבעים על היתר בניה שהוענק לאבי התובעים בשנת 1957. דא עקא, שבצדק טוענים התובעים כי יש לבחון את השאלה האם בוצעה "הרחבה דומה" בהתבסס על רישומו המקורי של הבית המשותף. במקרה דנן, הבית המשותף נרשם בשנת 1962 [ר' נספח ב' לתביעה], וכבר כלל את כל שלוש היחידות. דינה של טענת הנתבעים בעניין זה, להידחות אפוא.
06. שונים הם פני הדברים בנוגע לטענת הנתבעים, שלפיה, יש להתיר להם להותיר את הפרגולה על כנה, לאור העובדה שהיא מהווה הרחבה דומה למרפסות שנבנו על ידי התובעים. המדובר בשתי מרפסות שנבנו על ידי התובעים, האחת - מרפסת פתוחה, המצויה בצדו הצפוני של הבית המשותף [להלן: "המרפסת הפתוחה"], והשניה - המצויה בצדו המערבי של הבית המשותף - נקראת בפי הצדדים המרפסת הסגורה [להלן: "המרפסת הסגורה"].
16. אין ספק כי המרפסת הפתוחה לא מופיעה בתשריט הבית המשותף ומהווה תוספת מאוחרת לרישום. המרפסת הסגורה אכן מופיעה בתשריט הבית המשותף, אך היא רשומה כמרפסת, בעוד בפועל מדובר במרפסת שנסגרה [ר' עדות עד התובעים מר ביטון בעמוד 3 שורות 26-27 לפרוטוקול מיום 25.5.11].
26. מבנה הפרגולה ששטחה נע בין 9-10 מ"ר, כולל אמנם גג רעפים וקירות זכוכית משולבים בעץ, [ר': עדות הנתבע בעמוד 6 שורה 12 לפרוטוקול מיום 25.5.12, וכן סעיף 9 לסכומי התובעים], אך הוא אינו שונה מהותית מהמרפסת הנ"ל [זאת התרשמתי גם בעת ביקורי במקום]. ממילא, יש לראות בפרגולה כ"הרחבה דומה" למרפסות אלו, והתובעים אינם זכאים לדרוש הריסתה בנימוקים קנייניים. לא זו אף זו, לא הוכח על ידי התובעים כי מדובר בפרגולה המנצלת זכויות בניה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

36. אשר על כן, אני דוחה את התביעה בנוגע לדרישת התובעים להורות על הריסת הפרגולה.
46. ואחרון, יש לדון בדרישת הנתבעים שלא ליתן צו גורף ה אוסר כל בניה . מטבע הדברים , פסק דין הינו קונקרטי למקרה המובא בפני הערכאה השיפוטית , והוא אינו עוסק בשאלות תיאורטיות . גם במקרה דנן פסק הדין עוסק בתכנית הבניה מושא ה מחלוקת, ואינו קובע הוראות לגבי תכני ת ובקשות לתוספת בנייה שטרם באו לעולם . אכן, ייתכן מאוד כי לו היתה מוגשת בקשה לבניית ממ י"ד בגודל של עד 9 מ"ר, בשטח הצמוד לדירת הנתבעים, היתה המסקנה שונה , שכן בניית ממ י"ד בשטח זה אינה מהווה ניצול אחוזי בנייה עיקריים [ר' סעיף 9(ד)1] לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, וכן תקנה 197א ל תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990]. אולם, לא אלו פני הדברים , שכן במקרה דנן הממ"ד אמור להשתרע על שטח של 12 מ"ר [כך על פי תכניות הבניה] ולהיבנות מעל תוספת בנייה האסורה, כמפורט לעיל.

ה. סוף דבר:

56. התביעה מתקבלת ברובה , באופן שניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע בניה כמפורט לעיל. התביעה למתן צו הריסה כנגד הפרגולה נדחית.
66. הנתבעים יישאו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪.
- ניתן היום, י"א אלול תשע"ב (29 אוגוסט 2012) בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין